

1500485-40.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... em dinheiro trocado, proveniente do tráfico (fls. 9). Ao ser entrevistado, Felipe admitiu informalmente que estava traficando.

Conclui a denúncia que a quantidade de droga e as circunstâncias da prisão evidenciaram a destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fl. 100). Defesa preliminar apresentada às fls. 109/110. Após, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500485-40.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2083311/2021 - 04º D.P. PIRACICABA, 16988817 - 04º D.P. PIRACICABA, 100/21/527 - 04º D.P. PIRACICABA, 2083311 - 04º D.P. PIRACICABA, 2083311/2021 - 04º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE SILVA DE MORAIS

Contr. nº 2021/000325

Aos 15 de setembro de 2022, às 14:45 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu FELIPE SILVA DE MORAIS. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS Renan Borba de Souza e Jefferson Guimarães Gonçalves Marques

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os

trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Jefferson) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Renan, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).O réu FELIPE SILVA DE MORAIS foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. De acordo com a denúncia, o dia 25 de março de 2021, por volta das 9 horas e 40 minutos, na rua dos Pinheiros, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, FELIPE, qualificado de fls. 4/5, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 49 porções de maconha (fragmentos vegetais contendo Tetrahydrocannabinol), com peso bruto aproximado de 70,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (foto de fls. 9 e laudo de fls. 13). É da inicial réu se postou no local dos fatos para traficar drogas. Policiais Militares que patrulhavam pelo lugar, conhecido ponto de venda de drogas, suspeitaram da atitude de FELIPE, que, ao notar a viatura, demonstrou nervosismo. Decidiram, então, abordá-lo e submetê-lo à busca pessoal. Resultou a providência no encontro pelos PMS, em poder do indiciado, de 49 porções de maconha, além de R\$ 23,00 em dinheiro trocado, proveniente do tráfico (fls. 9). Ao ser entrevistado, FELIPE admitiu informalmente que estava traficando. O processo teve trâmite regular, conforme se observa a fls. 94, 100, 112 e 127/128. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 8; fotografia de fls. 9; laudo de constatação de fls. 11/13; laudo do exame químico-toxicológico de fls. 106/108. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os PMS contaram, em uníssono, que, durante o patrulhamento realizando pelo bairro Bosque Dos Lenheiros, quando transitavam pela rua dos Pinheiros, local conhecido como ponto de vendas de drogas, visualizam um indivíduo em atitudes suspeitas. Ao ver a viatura policial demonstrou exacerbado nervosismo, motivo pelo qual foi abordado. Identificaram o indivíduo como FELIPE SILVA DE MORAES e mediante uma revista pessoal, foi encontrado em seu poder uma bolsa contendo em seu interior 49 porções de maconha, além da quantia de R\$ 23,00. Ao questionarem o acusado, ele afirmou que as porções de droga eram de sua propriedade e que estava naquele local traficando. O PM Marques, em Juízo, corroborou o declarado na fase informativa e acrescentou que o réu estava parado e logo ao avistar a viatura começou a caminhar em sentido contrário, razão pela qual foi abordado. Disse, também, que o réu confessou informalmente a prática do tráfico de drogas. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. De fato, o réu foi abordado em ponto de drogas na posse de considerável quantia de entorpecentes e de dinheiro. Ademais, confessou informalmente a prática delitiva. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (Sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Assim, a condenação é de rigor. No tocante à aplicação da pena, a quantidade de drogas justifica aumento na primeira fase e o afastamento do privilégio, pois denota tráfico de média envergadura. O réu, entretanto, não possui antecedentes desabonadores (fls. 28 e fls. 29). Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).FELIPE SILVA DE MORAIS vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na

presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o acusado foi preso em flagrante após sofrer abordagem dos policiais militares que suspeitaram de sua conduta. Ocorre, porém, que ao explicarem os motivos que os levaram a suspeitar do réu, os policiais militares simplesmente disseram que ele demonstrou “nervosismo”. E isso evidencia a ilegalidade da medida tomada pelos policiais. De fato, como cediço, a revista pessoal é medida excepcional que só pode ser justificada diante da existência de fundada razão de que a pessoa abordada esteja em posse de arma proibida, objeto ou papéis que constituam o corpo de delito (art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal). Ou seja, para haver a busca pessoal, deve haver “fundada suspeita” da ocultação de algum objeto ligado ao crime. Mas isso não aconteceu. Na verdade, antes da abordagem, não existia qualquer dado concreto – e objetivamente aferível – de que o réu estaria praticando o crime de tráfico de entorpecente (ou qualquer outro delito). A abordagem dele se deu mediante critério meramente subjetivo, o que não é suficiente para autorizar a busca pessoal, sob pena de violação ao direito constitucional à intimidade (art. 5º, X, CF). Aliás, em caso semelhante, em que a pessoa foi abordada porque “fugiu” da viatura policial, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a revista pessoal foi ilícita: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes”. (HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça também entendeu como ilegal a busca pessoal efetivada após um suposto “nervosismo” da pessoa abordada: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no “nervosismo” apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). E, como se observa, o entendimento

do Tribunal Superior é no sentido que o fato do crime em questão (tráfico de drogas) ser classificado como permanente não importa, pois a suposta infração penal só veio à tona depois de uma abordagem feita a partir de mera conjectura. Portanto, a conduta dos agentes policiais que realizaram a abordagem/revista pessoal no acusado sem a existência de justa causa deve ser considerada ilegal. E uma vez reconhecida a ilicitude, todos os demais elementos derivados da busca igualmente devem ser tidos como ilegais, o que deve resultar na absolvição do réu, por ausência de provas válidas. Afinal, é evidente o nexo existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação. Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. De maneira subsidiária, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta do acusado para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas, considerando para tanto o teor do interrogatório do acusado, que alegou que estava em poder de menor quantidade de drogas, que seriam para seu uso. Afirmou que tinha cinco porções de maconha e não tinha dinheiro consigo. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente, que no caso dos autos é de menor efeito nocivo. Já na terceira etapa, requer-se a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que não há provas de que o réu é integrante de organização ou associação criminosa, o que fica demonstrado pela ínfima quantidade de droga apreendida. Além disso, trata-se de pessoa absolutamente primária, sem qualquer envolvimento com ato ilícito, nem mesmo na Vara da Infância e Juventude. Assim, a pena deve ser reduzida no patamar máximo, fixando-se, por consequência o regime inicial aberto. Presentes os requisitos legais, deve ainda a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, ao menos, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. Por fim, ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja autorizado ao acusado que apresente apelação em liberdade, se assim desejar.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

FELIPE SILVA DE MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2021, por volta das 9 horas e 40 minutos, na rua dos Pinheiros, bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 49 porções de maconha (fragmentos vegetais contendo Tetrahydrocannabinol), com peso bruto aproximado de 70,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (foto de fls. 9 e laudo de fls. 13).

Narra a denúncia que o acusado se postou no local dos fatos para traficar drogas. Policiais Militares que patrulhavam pelo lugar, conhecido ponto de venda de drogas, suspeitaram da atitude de Felipe, que, ao notar a viatura, demonstrou nervosismo. Decidiram, então, abordá-lo e submetê-lo à busca pessoal. Resultou a providência no

encontro pelos PMS, em poder do acusado, de 49 porções de maconha, além de R\$ 23,00 em dinheiro trocado, proveniente do tráfico (fls. 9). Ao ser entrevistado, Felipe admitiu informalmente que estava traficando.

Conclui a denúncia que a quantidade de droga e as circunstâncias da prisão evidenciaram a destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fl. 100). Defesa preliminar apresentada às fls. 109/110. Após, a denúncia foi recebida (fl. 112) e o réu foi citado (fl. 126).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade.

A Defesa pediu a absolvição, arguindo ilegalidade na ação dos policiais e sustentando que as provas dos autos não demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 06/07;
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 08 e fotografia de fls. 09;
- 3) laudo de constatação de fls. 11/13 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 106/108, ambos com resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) em relação à substância apreendida.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04), o réu permaneceu em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), disse que trazia consigo 5 porções de maconha, para seu uso. Não possuía dinheiro. Estava caminhando quando foi abordado. Não conhecia os policiais anteriormente. Atualmente trabalha com registro em carteira. A negativa foi afastada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase extrajudicial (fls. 02) e sob o crivo do contraditório (gravação), o policial militar Jefferson Guimaraes Gonçalves Marques declarou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Bosques dos Lenheiros. Afirmou que avistaram o acusado em atitude suspeita, num local já conhecido pela venda de drogas. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou grande nervosismo e tentou evitar a abordagem saindo em direção oposta. Diante da fundada suspeita de que estaria traficando no local, abordaram-no e, na revista pessoal, encontraram em sua posse uma bolsa contendo 49 porções de maconha e R\$ 23,00 em notas trocadas. Relatou que, ao questioná-lo, o acusado assumiu a propriedade da droga e confessou o tráfico.

No mesmo sentido as declarações prestadas pelo policial militar Renan Borba de Souza na delegacia de polícia (fls. 03).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA

FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos agentes da polícia não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo 49 porções de maconha, as quais eram destinadas ao comércio e consumo de terceiros, ficando, outrossim, afastada a tese defensiva de que os policiais agiram ilicitamente na

abordagem do acusado.

De fato, conforme revelou a prova supra analisada, o réu foi surpreendido pelos policiais militares parado em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e esboçou reação de nervosismo ao avistá-los, além de tentar evitar a abordagem, saindo em direção oposta à da viatura.

Sua atitude revelou a fundada suspeita da prática do crime permanente de tráfico de drogas e permitiu a lícita ação policial, com a abordagem e revista pessoal, ocasião que foram encontradas diversas porções de maconha e dinheiro trocado em sua posse.

Não há, assim, como se acolher a tese defensiva de ilicitude da ação policial e consequente nulidade das provas que comprovaram a posse dos entorpecentes pelo acusado.

Confirma o destino mercantil dos entorpecentes o fato de estarem fracionados e acondicionados em pequenas porções, como comumente são comercializadas (fotografia de fls. 09), bem assim a quantidade apreendida, incompatível com a situação do mero usuário.

Outrossim, o valor apreendido na posse do acusado, R\$ 23,00 em notas diversas, não teve sua origem lícita comprovada, presumindo-se ser produto das vendas ilegais. Registro que, ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO." (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - J. 20/07/2020). g.n.

"MATERIALIDADE - Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA - Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidem com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em houve apreensão de drogas em poder do menor - Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' - Validade - Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - Destinação a terceiros - Quantidade incomum com a figura do usuário - Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo - Apreensão de dinheiro - Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal - Denúncia - De rigor a condenação da ré - Absolvição - Impossibilidade - Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO - Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral - Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA - Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - natureza da droga de alto potencial lesivo - Manutenção - Presente a atenuante da menoridade - Redução da pena ao mínimo legal - Súmula 231 do STJ - Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 -

Mantença ante a inércia ministerial – Dedicação da ré à atividade criminosa – Passagem por ato infracional – Apreensão de considerável quantidade de droga – Profissionalização – Dedicação à atividade criminosa – Manutenção porque vedado a reformatio in pejus – Redução da pena – Impossibilidade – Improvimento ao apelo. REGIME – Fechado – Apreensão de elevada quantidade de droga – Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – Alta reprovabilidade e periculosidade – Ré que ostenta processo por ato infracional – O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) – Regime fechado – Necessidade – Improvimento ao apelo”. (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

O réu é primário e possui bons antecedentes (cf. F.A. de fls. 91/92).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade, mas deixo de diminuir as penas, uma vez que já fixadas no mínimo legal.

Inexistem agravantes ou causas de aumento de pena.

Presentes os requisitos do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes e não há notícias de que integre organização criminosa ou se dedique exclusivamente às atividades criminosas, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de fixação da pena, possível aplicação do entendimento explanado na decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que reconheceu a figura privilegiada nos crimes de tráfico de drogas nos casos de “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Referida decisão foi referendada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, revendo entendimento anteriormente consolidado naquela corte, cancelou o enunciado 512 da Súmula, afastando a hediondez no crime de tráfico privilegiado.

Essas Cortes Superiores têm reiteradamente pronunciado que o tráfico privilegiado, se não forem desfavoráveis ao réu as circunstâncias em que cometido, comporta regime aberto para início do cumprimento da pena e permite sua substituição por restritivas de direitos.

Assim, rendendo-me a tais posicionamentos e, considerando que todas as circunstâncias do crime praticado pelo réu, o qual é primário, lhe favorecem, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal.

Pelos mesmos motivos, substituo tal pena por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena substituída, e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi duas restritivas de direitos porque a pena substituída é superior a um ano (CP, art. 44, parágrafo 2º) e em razão da maior gravidade do crime, que fomenta a prática de vários outros delitos, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que não conseguem se livrar do vício.

Neste contexto, substituição por apenas uma pena restritiva de direitos e por uma pena pecuniária muito provavelmente não fariam com que o réu sentisse as graves consequências de seu ato e não seriam suficientes para impedir que continuasse a realizar o nefasto comércio.

Em casos como este, é necessária resposta firme do Estado para que a pena cumpra suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, eis que ausentes elementos que demonstrem a situação financeira do réu.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a



denúncia e CONDENO o réu FELIPE SILVA DE MORAIS a cumprir um ano e oito meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que, de acordo com os elementos acima analisados, restou demonstrado nos autos que a quantia apreendida em poder do acusado é decorrente do tráfico, com fundamento no artigo 63, "caput" da Lei 11.343/06, decreto seu perdimento em favor da União.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉU e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(<sup>a</sup>). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.